

1519928-23.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Elaine Cristina Pulcineli Vieira Gonçalves

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 15ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/03/2022

... reincidente específico, tendo sido condenado definitivamente por crime de tráfico perante a 10ª Vara Criminal Central autos nº 1501440-74.2018.8.26.0050, (fls. 40/41), o que será levado em consideração na segunda fase da aplicação da pena.

Por outro lado, nos termos que dispõe o art. 42 da Lei de tráfico, considerando a quantidade e a variedade de drogas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

15ª Vara Criminal

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1519928-23.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1519928-23.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MAXWELL OLIVEIRA BEZERRA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Elaine Cristina Pulcineli Vieira Gonçalves

Vistos.

MAXWELL OLIVEIRA BEZERRA e DAVID JÚNIOR ALBINO DE LIMA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no art. 33, caput, pois segundo apurado, no dia 18 de agosto de 2021, por volta das 13h20min., em ocasião de calamidade pública por conta da pandemia do novo coronavírus, na Rua da Cavalgada, na altura do nº 90, Vila Medeiros, na comunidade conhecida por "Favela do Violão", agindo em concurso e com identidade de propósitos, traziam consigo, para fim de tráfico, drogas, consistentes em 331 porções de "maconha", 286 "ependorfs" de "cocaína" e uma porção de "haxixe", sem autorização e em desacordo com autorização legal ou regulamentar, além da quantia de R\$ 97,00 (noventa e sete reais), em notas trocadas.

A denúncia foi recebida, os réus foram citados, notificados e apresentaram resposta à acusação.

Após a manutenção do recebimento da denúncia, designou-se audiência de instrução, debates e julgamento, durante a qual foram ouvidos dois policiais, uma testemunha de defesa, do acusado David, e os réus foram interrogados.

Encerrada a instrução criminal, o Ministério Público pugnou pela condenação dos réus nos exatos termos da denúncia.

Defesa do réu Maxwell pleiteou, em suma, pela absolvição do acusado por insuficiência probatória quanto a autoria do crime, e em caso de eventual condenação buscou o afastamento da agravante decorrente da pandemia, a fixação da pena-base em seu mínimo legal, o reconhecimento do "tráfico privilegiado" (art. 33,

§4º, da Lei 11.343/06) e consequente regime aberto para início de cumprimento, com substituição da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos e a concessão do direito de apelar em liberdade.

Já a Defesa do corréu David requereu a absolvição do réu por insuficiência probatória para a condenação, e em caso de eventual condenação pelo afastamento da agravante da pandemia, a fixação da pena-base no mínimo legal, a concessão do benefício previsto no §4º, do art. 33 da Lei 11.343/06, a fixação de regime de cumprimento de pena diverso do fechado de regime de cumprimento de pena em regime diverso do fechado, já que não há nos autos provas de que o réu se dedique a atividades criminosas, bem como o direito de apelar em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Não obstante as alegações da Defesa, analisando as provas colhidas nos autos, há provas suficientes para a condenação do acusado.

A materialidade do delito em questão restou comprovada pelo boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão das drogas, laudo de constatação e laudo pericial de fls. 139/141, com resultado POSITIVO para os entorpecentes apreendidos.

A autoria também é incontroversa.

O policial Marcelo, ao ser ouvido em juízo, afirmou que receberam uma denúncia de que na comunidade do violão havia duas pessoas na prática de tráfico de entorpecentes, próximo à Rua Cavalgada. Diante disso para lá se dirigiram, e após desembarcaram da viatura descaracterizada, e se dirigiram ao local indicado, a pé pela via, ocasião em que visualizaram o réu David com uma mochila a tira colo, ao lado de Maxwell, ambos conversando com um indivíduo e após uma troca manual entre eles, em ato típico de venda de drogas, resolveram abordá-los, ocasião em que dentro da mochila que estava na posse de David foram encontradas cerca de 600 porções de entorpecentes e com Maxwell uma quantia aproximada de R\$ 100,00. Diante disso, os dois foram presos e encaminhados à Delegacia de Polícia para a lavratura do boletim de ocorrência. No momento da abordagem os dois nada disseram, mas informalmente, já na Delegacia de Polícia ambos confessaram a prática do crime. No mesmo sentido, o outro policial Fabiano, disse que após receber denúncia anônima no sentido de que havia dois indivíduos praticando o tráfico de ilícito de entorpecentes na comunidade, e ao se aproximarem do local indicado visualizaram os réus próximos, conversando com outros indivíduos e após visualizarem atos típicos de venda de drogas se aproximaram e fizeram a apreensão de ambos. Disse que o rapaz que tem uma tatuagem no rosto estava com o dinheiro proveniente da venda das drogas e o outro com uma mochila onde foram encontradas mais de 600 porções de entorpecentes. Os réus nada disseram no momento da abordagem e já na Delegacia, informalmente confessaram o crime.

A testemunha de Defesa Ana Paula, mãe de David, não estava no local no momento em que seu filho foi preso. Disse que estava com o filho e parou na casa de uma tia para almoçar, ocasião em que David disse que ia comprar um cigarro e não mais voltou. Somente tomou conhecimento da prisão do filho, mais tarde quando chegou em casa. Disse que seu filho é usuário de maconha. Não conhecia os policiais que prenderam seu filho. E que David já foi preso por outro crime de drogas, mas que pelo que soube, estava no lugar errado, na hora errada.

O réu David, ao ser interrogado, em juízo, disse que foi até o local para comprar drogas e foi abordado pelos policiais que perguntaram sobre seus documentos também se tinha passagem. Assim que disse aos policiais que seu RG estava na caminhão junto com sua mãe e que já foi fora condenado por outro tráfico, acabou sendo preso. Disse que outro policial se aproximou e trazia, consigo uma mochila onde havia drogas e que não conhecia Maxwell que foi colocado na viatura junto com ele e levado para a Delegacia de Polícia.

Já Maxwell disse que pegou um dinheiro com seu patrão para pagar aluguel, e passou na Rua da Cavalgada para comprar drogas e de repente a polícia se aproximou e todos que estavam na rua correram. Os policiais o perseguiram e o prenderam no momento em que entrou na padaria.

Disse que a dona da Padaria, tem problemas de pressão e por isso não compareceu a audiência para relatar os fatos e ainda que não conhecia o corréu David.

Estas são as provas colhidas nos autos e diante delas, outra solução não há que a condenação de ambos os acusados.

Isso porque, embora os réus tenham negado a prática do crime, suas versões são incríveis e não vieram corroboradas com outras provas.

Já os dois policiais, em todas as oportunidades em que foram ouvidos afirmaram que após receberem uma denúncia sobre o tráfico de drogas na Rua da Cavalgada, para lá se dirigiram e viram os dois réus em atitude típica de venda de entorpecentes, o que confirmou a denúncia e diante disso os abordaram sendo que com um havia uma mochila dentro da qual estavam as drogas e com o outro o dinheiro.

É de asseverar, ainda, que o simples fato de as testemunhas ouvidas serem policiais nada significa para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que estes sejam recebidos com reservas, mesmo que não tenham sido arroladas outras testemunhas.

Neste compasso, imprescindível salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que os depoimentos de policiais, apenas pela sua condição, não podem ser desconsiderados ou desacreditados, em primeiro lugar porque, constitucionalmente, são os policiais aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei.

Confira-se: "Prova - Testemunhal - Depoimento prestado por policiais participantes da diligência - Validade - Ausência de interesse em incriminar o réu - Recurso não provido. Os funcionários da Polícia merecem, em seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão, concreta de suspeição" (Relator: Silva Pinto, Apelação Criminal n. 153.983-3, Santos, 7.7.94).

De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública o direito (e o dever) de prestar contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento.

A desconsideração de depoimento de policial somente procede quando decorre de atos de parcialidade, motivados por vingança ou perseguição e desde que comprovados de forma segura e objetiva, o que efetivamente não veio a ser comprovado nestes autos, muito embora tenha o réu tentado caracterizar de tal forma.

Não é suficiente a mera alegação de suspeição em virtude de simplesmente tratar-se de agentes policiais. Ressalte-se que a diligência policial promovida nestes autos se deu após uma denúncia anônima, segundo a qual duas pessoas estavam no local traficando entorpecentes, sem que haja qualquer indício de perseguição pelos policiais em relação aos acusados.

De outra banda, a quantidade e a variedade de droga apreendidas, o dinheiro encontrado, e ainda o local em que os dois réus, e o fato de que ambos foram vistos conversando com um indivíduo que após um troca manual, deles se afastou, já são suficientes para caracterizar o crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.

A este propósito, é expressiva a jurisprudência, merecendo destaque o seguinte julgado: "PROVA CRIMINAL - Tóxico - Tráfico - Quantidade da droga apreendida, aliada a outras circunstâncias, que induzem à certeza de destinação ao comércio - Recurso não provido". (Relator: Lustosa Goulart - Apelação Criminal n.º 159.552-3 - São Paulo - 05.05.94).

Assim é que a versão dos acusados no sentido de que são meros usuários de drogas não foi corroborada nos autos, ainda mais porque, nenhum deles disse que portava qualquer tipo de droga.

Quanto ao corréu Maxwell, embora ele não tenha sido apreendido com as drogas, fato é que estava no local, junto com David, (que era quem efetivamente trazia consigo as drogas) e foi preso com o dinheiro proveniente da venda. Portanto, comprovada está sua participação no crime de tráfico, já que no concurso delinquencial não se faz mister que todos os partícipes consumem atos típicos de execução: para ser alguém corresponsável, basta que se constate haja colaborado para o evento, auxiliando (física ou moralmente), instigando, prestigiando ou encorajando (em certas situações com a simples presença voluntária) a atuação dos executores diretos e neste passo releva notar que a denúncia anônima afirmou que dois eram os traficantes e os policiais foram firmes em dizer que um indivíduos se aproximou de onde ambos estavam, um com o dinheiro e o outro com as drogas, o que não deixa dúvida o concurso de agentes.

Caracterizada, portanto, a infração penal a condenação é medida que se impõe. Dessa forma, passo a dosar a pena.

Do réu David:

O réu é reincidente específico, tendo sido condenado definitivamente por crime de tráfico perante a 10ª Vara Criminal Central autos nº 1501440-74.2018.8.26.0050, (fls. 40/41), o que será levado em consideração na segunda fase da aplicação da pena.

Por outro lado, nos termos que dispõe o art. 42 da Lei de tráfico, considerando a quantidade e a variedade de drogas apreendidas com o réu, aproximadamente 600 porções de cocaína, maconha e haxixe, a pena base será aumentada em 1/6, em 1/6, totalizando 05 anos, 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na segunda fase, há que se considerar a reincidência específica e ainda que o crime foi cometido em meio à pandemia da COVID 19, reconhecida por meio do Decreto nº 64.879/2020 de 20/03/2020. Neste ponto, não obstante posições em contrário, há que asseverar que para esta magistrada, o estado de calamidade pública acabou por facilitar a execução de crimes, ainda mais diante da necessidade de isolamento social a fim de retardar a propagação da doença, o que gerou a redução de pessoas e policiais nas ruas, defasando a vigilância estatal. Assim sendo, a pena deve ser agravada em mais 1/5, alcançando o patamar de anos de reclusão e 699 dias-multa. Neste sentido, já se manifestaram nossos Tribunais:

“Na segunda fase, o crime foi praticado durante o período de calamidade pública causada pela pandemia do COVID-19, nos termos do Decreto Estadual nº 64.879/20. Justifica-se a aplicação da agravante mencionada, uma vez que o cometimento do crime nessas circunstâncias de calamidades públicas demonstra insensibilidade moral do agente para com a solidariedade social, visto que o período impõe o dever social de recíproca assistência. Ademais, é um período em que há maiores dificuldades de policiamento, por exemplo, e o agente aproveita-se disso para a prática de delitos” (TJ-SP – PR: 15078616020208260228 SP 1507861- 60.2020.8.26.0228, Relator: Tetsuzo Namba, Data de Julgamento: 21/07/2020, 11ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 21/07/2020).

E ainda: “(...) Por outro lado, cabível a manutenção da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea j, do CP. Ora, o acusado praticou o presente crime durante período de calamidade pública (pandemia), instituído pelo Decreto Legislativo nº 6, do Congresso Nacional, e Decreto nº 64.879, do Estado de São Paulo, ambos em vigor na data em que perpetrado o delito em apreço, não podendo prosperar a alegação de suposto desconhecimento, mormente porque decretadas diversas restrições a toda população, para fins de contenção da doença. De se sublinhar, outrossim, que se trata de agravante de caráter objetivo, não se exigindo, portanto, requisito outro adicional que não a mera existência do estado emergencial, a atribuir maior grau de reprovabilidade às condutas ilícitas perpetradas durante sua vigência” (Apelação Criminal 1509419- 67.2020.8.26.0228. Rel. Edison Brandão. Quarta Câmara de Direito Criminal TJSP. J. 26/01/2021).

“Não há que se falar em afastamento da agravante relativa ao cometimento do crime durante estado de calamidade pública. Isso porque trata-se de circunstância de caráter objetivo, bastando que o crime ocorra durante aquele estado emergencial, não havendo exigência legal da presença de outros requisitos para a sua configuração. Com efeito, é de notório conhecimento o reconhecimento do estado de calamidade pública decorrente da pandemia do COVID-19 até 31 de dezembro de 2020, conforme Decreto Legislativo nº 06, de 20 de março de 2020. Assim, qualquer indivíduo que cometa crimes no período compreendido no citado decreto, como no caso em comento, terá sua pena agravada, haja vista que o agente se vale de uma situação dramática pela qual passa o país para delinquir. Irrelevante, ainda, que não seja o criminoso o provocador da situação excepcional; o que prevalece é sua atitude de se valer das facilidades que dela decorrem, in casu, o isolamento social, com diminuição do policiamento, por exemplo. Sobreleva registrar, outrossim, que as calamidades públicas impõem o dever social de mútua assistência, e o cometimento de crime nessas circunstâncias demonstra insensibilidade para com os mandamentos emanados da solidariedade social. A calamidade produz situação de incapacidade, total ou parcial, de defesa por parte da sociedade, e a exigência de abstenção da

conduta é maior do que no caso de não concorrerem tais circunstâncias.” (TJSP, Apelação Criminal nº 1512914-22.2020.8.26.0228, Rel. Des. Camilo Léllis, 4ª Câmara Criminal, j. 09/0).

A 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo Autos nº 1509419-67.2020- “O acusado praticou o presente crime durante período de calamidade pública (pandemia), instituído pelo Decreto Legislativo nº 6, do Congresso Nacional, e Decreto nº 64.879, do Estado de São Paulo, ambos em vigor na data em que perpetrado o delito em apreço, não podendo prosperar a alegação de suposto desconhecimento mormente porque decretadas diversas restrições a toda população, para fins de contenção da doença”, escreveu o magistrado em seu voto. “De se sublinhar, outrossim, que se trata de agravante de caráter objetivo, não se exigindo, portanto, requisito outro adicional que não a mera existência do estado emergencial, a atribuir maior grau de reprovabilidade às condutas ilícitas perpetradas durante sua vigência.”

O Decreto Legislativo nº 06/2020, do Congresso Nacional, e o Decreto Estadual nº 64.879/2020, reconheceram a situação de calamidade pública resultante da pandemia concernente ao novo coronavírus. E o reconhecimento de tal circunstância motiva a incidência de referida agravante.

Ora, diante de tal situação de calamidade pública, a população foi orientada e, em algumas cidades, forçada, a fechar-se em casa. Vários estabelecimentos comerciais foram obrigados a cerrar portas. Esforços financeiros e humanos foram dirigidos pelo Estado ao combate à pandemia.

Desse modo, toda a sociedade foi atingida e sofreu as consequências de referida pandemia, a qual foi reconhecida como calamidade. É indiscutível que o cometimento de qualquer crime durante tal circunstância encontra maior facilidade e superior reprovabilidade, fazendo jus à respectiva exacerbação da reprimenda.

Pese tenha inteligência no sentido de emprestar uma interpretação mais restritiva para a norma prevista no artigo 61, inciso II, “j”, do Código Penal, a Câmara assentou entendimento pela incidência da circunstância agravante numa situação como a dos autos.

A compreensão é de, com o estado de calamidade provocado pela ação do coronavírus (declarado pelo Decreto Legislativo 06/2020, do Congresso Nacional), “a população foi orientada e, em algumas cidades, forçada a ficar em casa. Vários estabelecimentos comerciais foram obrigados a fechar. Esforços financeiros e humanos foram dirigidos pelo Estado ao combate da pandemia.

Desse modo toda a sociedade foi atingida e sofreu as consequências de referida pandemia, a qual foi reconhecida com calamidade. É indiscutível que o cometimento de qualquer crime durante tal circunstância encontra maior facilidade e superior reprovabilidade, fazendo jus à respectiva exacerbação da reprimenda” (Apelação nº 1512223-08.2020.8.26.0228, rel. Des. Hermann Herschander).

Não se exige na linha do que penso - que o agente se aproveite especificamente do quadro de pandemia para a realização do crime, ou seja, que essa situação tenha facilitado, de alguma maneira, a ação criminosa. É suficiente, para a incidência da circunstância agravante, que o crime tenha sido cometido durante o período de calamidade pública critério temporal puramente objetivo. Orientação que acompanho nesta oportunidade, em atenção ao princípio da colegialidade (STF, Ag. Reg no RHC nº 142.585, rel. Min. Celso de Mello).

STJ - “(...) impende destacar que os autuados foram presos em flagrante durante o período de calamidade pública, decorrente da pandemia do COVID-19, circunstância que eleva a reprovabilidade de suas condutas, eis que previsto como agravante genérica (art. 61, II, 'j', do CP). Veja-se que nem mesmo o alto risco de contágio foi motivo suficiente a ser ponderado pelos indiciados a fim de dissuadi-los do intento deletério de cometerem os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Não se pode olvidar também que os averiguados descumpriram orientações do Ministério da Saúde de isolamento social, o qual está sendo amplamente divulgado nos meios de comunicação. Assim, as condutas dos autuados revestem-se de maior gravidade, eis que aumentaram os índices de disseminação do vírus COVID-19 a toda população do Município, colocando em risco a saúde pública” (HC nº 584.871, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 04.06.2020, DJe 08.06.2020).

TJSP - APELAÇÃO CRIMINAL (...) Afastamento da agravante prevista no art. 61, II, 'j', do CP Descabimento Crime cometido durante o estado de calamidade pública decorrente do COVID-19 Inexigência legal de outros requisitos para caracterização da agravante (...) Recurso desprovido. (TJSP, Apelação Criminal nº 1510315-13.2020.8.26.0228, Rel. Camilo Léllis, 4ª Câmara de Direito Criminal, J. 16.10.2020). Com idêntico raciocínio: Apelação nº 1507788-88.2020.8.26.0228, Rel. Des. Camargo Aranha Filho, j. 21.09.2020; Apelação nº 1513982-07.2020.8.26.0228, 7ª Câmara Criminal, Rel. Des. Freitas Filho, j. 19.01.2021.

A 9ª Câmara Criminal, também assim se manifestou em voto proferido pela Des. Fátima Gomes: "Com efeito, na alínea "j" do inciso II do art. 61 do Código Penal, encontra-se previsão para a agravação da pena diante de circunstâncias que representem o aproveitamento por quem realiza o crime da existência de uma situação de perigo comum. Cabe notar não ser necessário que o sujeito crie a situação de perigo, mas que apenas a aproveite. As calamidades públicas impõem o dever social de mútua assistência, e o cometimento do crime nessas circunstâncias demonstra insensibilidade para com os mandamentos emanados da solidariedade social. A calamidade produz situação de incapacidade, total ou parcial, e a exigência de abstenção da conduta é maior do que no caso de não concorrerem tais circunstâncias. Na situação especial, o apelante aproveitou-se de acontecimentos de especial relevo para a vida da população. O acontecimento e seus efeitos maléficos devem, obrigatoriamente, ser conhecidos por quem deles conscientemente aproveita-se. Nesse sentido: "Essa circunstância implica maior gravidade do injusto, de modo a agravar o desvalor da ação, dado que a produção do resultado delituoso se revela mais provável. É necessário que o agente tenha se aproveitado, de modo consciente e voluntário, da ocasião ou do momento particularmente difícil em que se encontra a vítima, com o fim de dificultar sua defesa. Tal agravante também se fundamenta em razões político-criminais, pois o agente pode prevalecer-se das circunstâncias não apenas para debilitar a defesa da vítima, mas também para facilitar sua impunidade." (PRADO, Luiz Regis. Comentários ao Código Penal: Jurisprudência, Conexões Lógicas com os Vários Ramos do Direito. 10. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 335).

Assim, referida agravante tem natureza objetiva, estampada no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal e, diante da notória calamidade pública gerada pela pandemia do vírus covid-19, mostra-se absolutamente desarrazoada a pretensão defensiva de afastá-la".

Na terceira fase, há prova de que o réu é reincidente específico e que, portanto, se dedica a atividades criminosas. Portanto, nos termos do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, não há que reduzir a pena do acusado.

Nesse particular, não há falar em bis in idem pelo simples fato de a reincidência servir agora como fundamento para agravar a pena e também impedir a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33, da Lei de Drogas, como vem decidindo nossas cortes superiores.

Isto porque, "...na aplicação do preceito em foco, o Juiz há de verificar, também, a culpabilidade do agente e as circunstâncias do crime, sem o que estará ferindo o princípio da individualização da pena, não se podendo falar em bis in idem por ter sido a reincidência considerada para aumentar as sanções e também impedir a incidência do redutor do artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, pois a aplicação de tal dispositivo exige a ocorrência simultânea de todas as Condições mencionadas, ou seja, ser o agente primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividade criminosa e nem integrar organização criminosa, o que não é o caso do acusado". Conforme já decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema, "não há que se falar em bis in idem mas sim em cumprimento dos efeitos lógicos, legalmente previstos, decorrentes de um mesmo instituto jurídico a reincidência quando foi agravada a sanção do paciente na segunda etapa da dosimetria, dado o reconhecimento da agravante do art. 61 do CP, e deixou-se de fazer incidir a causa especial de diminuição da pena inserta no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, em razão da não primariedade do paciente" (HC 118403/SP, 5ª Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJE 15.12.2009)." (TJSP, Apel. Crim. nº 990.10.184009-0, 5ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. Tristão Ribeiro).

Do réu Maxwell:

O réu é primário e não possui antecedentes criminais, assim sendo a pena base deve ser fixada no mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase há que se reconhecer a agravante prevista no art.61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, já que o crime foi cometido em situação de calamidade pública tendo em vista a pandemia que assola o país por conta do coronavírus - COVID-19, reconhecida por meio do Decreto nº 64.879/2020 de 20/03/2020. Nesse contexto, respeitadas posições em contrário, para esta magistrada, não há como se afastar tal agravante pelos motivos e fundamentos acima já expostos.

Assim sendo a pena deve ser aumentada em 1/6, chegando-se a 05 anos, 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento de pena a serem levadas em conta, por outro lado, a grande quantidade de drogas encontrada em poder do comparsa do acusado, (reincidente em crime de tráfico) cerca de 600 porções separadas e já prontas para o consumo, e ainda o fato de que o dinheiro da venda estava com o réu Maxwell, é para essa magistrada prova de que ele se dedica a atividade criminosa, já que não é crível que alguém confie a um desconhecido o valor adquirido com as vendas das drogas. Portanto, deixo de aplicar o disposto no do § 4º, do art. 33, da lei 11.343/06.

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal que a Justiça Pública move contra o réu DAVID JÚNIOR ALBINO DE LIMA, para CONDENÁ-LO à pena de 07 anos de reclusão e ao pagamento de 699 dias-multa, calculados na base do valor unitário mínimo, e contra MAXWELL OLIVEIRA BEZERRA também para condená-lo e à pena de 05 anos 10 meses de reclusão e ao pagamento de 583 dias-multa, calculados na base do valor unitário mínimo, já que não há nos autos provas da condição econômica dos acusados, por estarem incursos no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006.

Nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, os réus cumprirão a pena em regime inicial fechado, seja ainda em razão reincidência do corréu David.

Em razão de estarem respondendo ao processo presos, tem-se entendido que seria um contrassenso libertá-los após a sentença que os condenou.

Ademais, remanesçam presentes os requisitos da custódia cautelar (art. 312 do CPP), destarte, não poderão recorrer desta sentença em liberdade.

Recomendem-se os réus na prisão em que se encontram, já que ainda persistem os motivos ensejadores da prisão cautelar, que deve ser mantida, notadamente, para a garantia da ordem pública, já que este delito é o que sustenta várias organizações criminosas que com o dinheiro adquirido com a venda de entorpecentes se armam cada vez mais e melhor para a prática de inúmeros delitos.

Diante disso, em cumprimento ao art. 316, do CPP, já com a nova redação, dou por revisada de ofício a decisão que determinou a prisão preventiva dos réus, que deve ser mantida pelos fundamentos acima expostos.

Após, o trânsito em julgado, expeça-se guia, oficiem-se aos TRE e ao IIRGD.

Decreto a perda do dinheiro apreendido, em favor da União, nos termos legais.

Determino, ainda, se o caso destruição de toda droga apreendida, inclusive eventual quantia guardada para contraprova, nos termos legais.

Custas na forma da lei. Deixo de isentar o réu do pagamento da referida taxa, já que não compete a este juízo esta decisão, ainda mais porque, não há os autos qualquer prova da condição econômica do réu. Neste sentido: Apelação Criminal nº 1504000-37.2018.8.26.0228, 5ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo).

P.R.I.C.

São Paulo, 04 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA